Wolters Kluwer | LEGGI D'ITALIA Legale

Cass. civ. Sez. V, (ud. 16/03/2005) 28-09-2005, n. 18962

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente
Dott. MONACI Stefano - Consigliere
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocato dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da AGENZIA DELL'ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocato dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -

contro

CAVA SAN BIAGIO SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 12607/04 proposto da:
CALCESTRUZZI SPA, che ha incorporato la CAVA SAN BIAGIO SRL con atto pubblico notaio F. CALARICO di BERGAMO stipulato il 20.12.00 in persona dell'amministratore delegato Dott. MARIO COLOMBINI elettivamente domiciliato in roma via PO 9, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, difeso dall'avvocato SERI MANUEL, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELL'ENTRATE in persona del Direttore pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1/03 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 12/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/05 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il resistente l'Avvocato SERI MANUEL che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. La Cava S. Biagio srl (già incorporante de "La Risorta" srl e della "Cave riunite" srl, con effetti dall'1.1.1992) impugnava il silenzio-rifiuto opposto dalla Direzione Regionale delle Entrate - Sez.staccata di Ancona - alla istanza di rimborso dell'irpeg e dell'ilor relative all'anno 1992. La società aveva inoltrato l'istanza assumendo che, relativamente a tale annualità, era stato erroneamente indicatola le variazioni in aumento del reddito, l'importo di L. 121.618.492: corrispondente alla quota di ammortamento (1/5) relativa alla iscrizione in bilancio dell'avviamento (L. 608.092.460) derivante dalla incorporazione della predetta La Risorta srl.
Il ricorso veniva accolto dalla adita Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, con sentenza n. 387/01/2000.
L'Ufficio finanziario proponeva appello contro tale sentenza, assumendo: in primo luogo, di essersi (contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici) costituito tempestivamente in giudizio, stante la mancanza di perentorietà del relativo termine;in secondo luogo, e nel merito, che era precluso alla contribuente il rimborso di quanto richiesto, essendo tra le parti intervenuti in data 7.4.2000, a seguito della notifica di due avvisi di accertamento, altrettanti atti di adesione con relativa definizione del reddito imponibile per l'anno 1992 (cui aveva anche fatto seguito il pagamento del dovuto da parte della contribuente).
Con sentenza n. 01/04/03 depositata il 12.2.2003, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, nel costituito contraddittorio delle parti, riteneva - in rito - ammissibile la costituzione dell'Ufficio nel giudizio di primo grado.
Nel merito, invece, privo di fondamento l'appello, in quanto, anche sulla base della documentazione (avvisi di accertamento e atti di adesione) acquisita ex officio, gli avvisi di accertamento - emessi ai sensi dell'art. 41 bis DPR 602/1973 - risultavano avere riguardato la sola esenzione decennale dall'ilor; mentre gli atti di

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

adesione (peraltro riferiti espressamente a tali avvisi di accertamento) avevano avuto ad oggetto la sola rideterminazione consensuale della quota di reddito esente ai fini dell'ilor stessa.
Sicchè, tali atti di adesione dovevano ritenersi ininfluenti rispetto alla domanda di rimborso de qua:domanda peraltro in se stessa fondala, attesa la deducibilità ai fini fiscali delle quote di ammortamento. Ricorrono congiuntamente per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con un articolato mezzo di doglianza.
Si è costituita e resiste con controricorso la Calcestruzzi spa (incorporante della Cava S. Biagio srl) la quale propone anche contestuale ricorso incidentale (condizionato all'accoglimento di quello principale), sostenuto da due mezzi.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale, afferenti la medesima sentenza.
3. Ciò posto, va osservato che la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma quarto Dlgs.vo 218/1997 e dell'art. 42 DPR 600/1973 nonchè motivazione contraddittoria ed omesso esame di un punto decisivo della controversia. Le censure sono fondate.
Al riguardo è da ritenersi che, una volta comunque rideterminato, in via di adesione, il reddito imponibile ed assolto dalla società a quanto dovuto (ai fini dell'irpeg e dell'ilor) sul reddito così rideterminato non possono essere prese più in considerazione delle istanze di rimborso afferenti l'annualità definita; pena l'alterazione, in contrasto con quanto disposto dall'art. 2 comma terzo D.Lgs.vo 218/1997, della misura della base imponibile concordata fra le parti.
Invero, l'art. 1 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l'accertamento delle imposte sui redditi (e dell'imposta sul valore aggiunto) può essere definito con adesione del contribuente; e l'art. 2 comma 3 della indicata fonte normativa stabilisce, per quanto qui rileva, che "l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione" e che lo stesso "non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio..." (salvo i casi, che qui non ricorrono, di cui al comma 4 del citato art. 2).
Da tale disciplina normativa si ricava chiaramente che, da parte del contribuente, il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai rimesso in discussione.
Pertanto, deve ritenersi erroneo il contrario convincimento al riguardo manifestato dai Giudici di appello.
4. La riconosciuta fondatezza del ricorso principale dell'A.F. impone l'esame di quello, incidentale, condizionato all'accoglimento del primo, proposto dalla società.
La ricorrente in via incidentale con un primo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 D.Lgs.vo 546/1992.
Con un secondo motivo, al precedente connesso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma primo D.Lgs.vo 546/1992, con riguardo alla avvenuta acquisizione, con ordinanza istruttoria n. 20/04/02, degli avvisi di accertamento e dei relativi atti di adesione. Ad avviso della società siffatta acquisizione sarebbe illegittimamente avvenuta: sia perchè, in considerazione della tardiva costituzione dell'Ufficio finanziario, era preclusa ogni indagine al riguardosa perchè, in tal modo operando, la Commissione aveva finito per sopperire al mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, ad un proprio specifico onere probatorio.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione, sono prive di fondamento.
Ritiene la Corte che i Giudici di appello del tutto correttamente abbiano nella specie ritenuto di escludere qualsiasi conseguenza radicale di ordine processuale (inammissibilità) per via della tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio innanzi alla CTP. Invero, nel sistema del contenzioso tributario introdotto con il D.Lgs. 546/1992, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, altrimenti la parte decade dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa (art. 23 D.Lgs. 546/1992).
Peraltro, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 7329/2003), qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessun altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente.
Sicchè, deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità - anche perchè non prevista dall'art. 23 cit., a differenza di quanto previsto, per la costituzione del ricorrente, dall'art. 22 della medesima fonte normativa - per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente (attività queste che il Giudice svolge ex officio, dovendo comunque verificare la fondatezza in fatto e in diritto della domanda); sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 D.Lgs. 546/192: facoltà esercitabile anche in appello ex art. 58 comma 2 D.Lgs. ora cit.
Nella specie, premesso che le difese della Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ancona, risultano (come accertato dalla CTR) essersi svolte in primo grado nell'ambito del consentito, da rilevare che l'acquisizione degli atti disposta dalla stessa CTR con apposita ordinanza istruttoria è perfettamente legittima.
Invero, giusta quanto previsto dall'art. 7 comma terzo D.Lgs.vo 546/1992, "è sempre dato alle commissioni tributarie di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia".
I Giudici di appellerei libero apprezzamento circa la necessità, ai fini del decidere sulla domanda di rimborso della contribuente, di acquisire gli avvisi di accertamento notificati alla stessa ed i seguenti atti di accertamento adesione intervenuti inter partes, hanno disposto in tal senso, ed al relativo ordine l'A.F. ha correttamente ottemperato, producendo la documentazione richiesta:
poi utilizzata effettivamente dalla CTR ai fini della formazione del proprio convincimento.
Trattandosi di esercizio di una facoltà discrezionale, prevista dalla leggero stesso non è sindacabile in questa sede.

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

5. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto, e rigettato invece, quello incidentale.
In relazione all'accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio - occorrendo ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità - ad altra sezione della CTR delle Marchesa quale, uni formandosi ai principi di diritto enunciati, provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati